

1500399-08.2022.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... instaurada para a apuração dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico com causa de aumento pelo fato do agente envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.

Presente as condições e não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo à análise do mérito.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes (FATO 01) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-08.2022.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-08.2022.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134522/2022 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 25033883 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2134522 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ALEX SANDRO DOS SANTOS SILVA, já devidamente qualificado nos autos, em decorrência da suposta prática dos delitos previstos nos arts 33, "caput" e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta na denúncia (fls. 80-83), no dia 17 de maio de 2022, na Avenida das Cerejeiras, nº 138, Jardim Europa, e na Rua Finlândia, nº 52, Parque das Nações, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, ALEX SANDRO, com a colaboração e

envolvimento do adolescente Gabriel Henrique Ferreira, de 15 anos, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, tinham em depósito e mantinham a guarda, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 28 porções de maconha com massa bruta total de 42 gramas, sob a guarda de ALEX SANDRO; e mais 99 porções de mesma droga massa bruta total de 889,15 gramas, sob a guarda do adolescente, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (FATO 01). Consta, ainda, que a partir de data incerta, mas até o dia 17 de maio de 2022 (data da prisão), nesta cidade e comarca, ALEX SANDRO e Gabriel Henrique Ferreira, de 15 anos, em unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 02).

De acordo com o Ministério Público, ALEX SANDRO e o adolescente, mediante unidade de desígnios e comunhão de esforços, associaram-se para promoção, de forma estável e permanente, do comércio espúrio de drogas, mediante guarda e venda compartilhada de entorpecentes, especialmente maconha, e divisão de lucros.

Houve que, por ocasião do FATO 01, Gabriel foi visto, em via pública, por uma guarnição da Polícia Militar em atitude suspeita, pois empreendeu fuga ao notar aproximação da viatura, razão pela qual foi alcançado e detido pelos agentes de segurança pública. Em seu poder, os policiais encontraram 2 porções de maconha e a quantia de R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais). Indagado a respeito, o jovem relatou que estava indo até a casa de seu comparsa ALEX SANDRO, para fazer o “recolhe”, ou seja, receber dinheiro proveniente da venda compartilhada de drogas. Em razão disso, os diligentes policiais seguiram até a residência do acusado. Chegando lá, a genitora de ALEX SANDRO franqueou a entrada e os policiais encontraram, dentro do quarto do increpado, mais 28 porções de maconha, acondicionadas em sacos plásticos para “geladinho”, prontas para a venda a usuários. Já na casa de Gabriel, precisamente debaixo da cama do adolescente, havia mais 97 porções da mesma droga, 1 balança de precisão, 1 rolo de plástico filme transparente, 70 sacos plásticos para “geladinho” e a quantia de R\$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos).

Por ocasião dos fatos, também foram apreendidos dois telefones celulares. A quantidade, forma de acondicionamento, circunstâncias da ação criminosa, apreensão de balança de precisão e tudo mais quanto consta dos autos comprovam o narcotráfico para o Ministério Público.

Outrossim, a quantidade total de maconha, suficiente para realização de inúmeras transações ilícitas, a prévia e clara divisão de tarefas, com “recolhe” de dinheiro e fracionamento do depósito da droga em mais de imóvel, bem como outras circunstâncias que serão melhor esclarecidas ao longo da instrução, demonstram, para o Parquet, a associação com ânimo de estabilidade e permanência para promoção do tráfico de drogas.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 85-87, seguindo-se a regular citação do réu às fls. 99, com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 133-134).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado os réus. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 221-228). A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou, em relação ao tráfico, a desclassificação da o delito do art. 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e os consectários na fixação do regime e substituição da pena privativa de liberdade.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico com causa de aumento pelo fato do agente

envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.
Presente as condições e não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo à análise do mérito.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes (FATO 01)

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 10-13), auto de exibição/apreensão (fls. 14-15 e 18-19), auto de constatação preliminar (fls. 16-17) laudos periciais positivos para maconha (fls. 103-108, 109-112, 113-116, 119-122 e 123-128), análises investigativas de telefones celulares (fls. 183-200) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu, interrogado na fase policial, disse que: na data em questão, tinha acabado de chegar da escola e foi dormir; acordou com a equipe da polícia batendo em sua porta, juntamente com Gabriel; na hora em que tinha ido buscar a chave para abrir a porta para os policiais, estes já tinham arrebentado o portão e entrado em sua casa; foi questionado se tinha entorpecentes; disse que tinha apenas 38 "balas" de maconha e que usa para consumo próprio; os policiais procuram mais entorpecentes, mas em sua residência só estavam as 38 balas de maconha; os policiais foram até a casa da avó do Gabriel onde foram encontrados o restante dos entorpecentes; o restante não é dele, e sim de Gabriel; não realiza trafico de entorpecentes, apenas utiliza droga para seu consumo próprio; fuma maconha com Gabriel (fls. 07).

Interrogado em juízo, disse que: a maconha encontrada na sua casa é de sua propriedade pois é usuário crônico de maconha para se acalmar; nega a associação para o tráfico; nem é próximo de Gabriel; a droga foi encontrada dentro do guarda-roupa do depoente; não procede a afirmação de Gabriel de que o adolescente arremessou a droga em seu quintal; estava dormindo em sua casa quando os policiais entraram e falaram que o depoente era traficante e que a casa tinha caído; a mãe do depoente chegou e viu a abordagem; os policiais levaram o depoente até a casa de Gabriel e depois foram para o trabalho da avó de Gabriel; na Delegacia viu as drogas encontradas em sua residência e com Gabriel.

A testemunha, Adriano da Costa Pucci, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar; na data em questão, estava juntamente com o PM SD Cristine, em patrulhamento de rotina no Bairro Jardim Europa na Avenida das Cerejeiras; visualizou o menor Gabriel Henrique Ferreira que, ao avistar a viatura, tentou correr, desviou o seu rumo; o menor foi detido; na abordagem foi possível localizar consigo 02 porções de maconha e a quantia de R\$ 181,00 em espécie; ao questioná-lo sobre a origem dos entorpecentes e do dinheiro, respondeu dizendo que estava indo na casa de seu colega ALEX fazer o "recolhe" do dinheiro, pois deixou com ele mais de 20 porções de maconha para ele vender; Gabriel mostrou onde ALEX morava, com isso a genitora de ALEX franqueou a entrada da equipe para entrar na casa; dentro de seu quarto, mais especificamente no guarda roupa fora possível localizar 28 porções de maconha; Gabriel o informou que reside na casa de sua avó na Avenida Amazonas no numeral 474, e que por lá guardava mais entorpecentes; Gabriel autorizou a entrada da equipe em sua casa; em seu quarto em baixo da cama mostrou onde guardava as drogas, totalizando mais 47 porções pequenas de maconha, 40 porções grande de maconha, 1 balança de precisão sem marca, embalagens para preparar as drogas e mais R\$ 11,80 em moedas; foi dado voz de prisão a ALEX e o menor conduzido até o plantão policial para registro de ocorrência. (fls. 03).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Europa e visualizaram Gabriel que, quando viu a viatura mudou o rumo, tentou correr e acelerou o passo, o que motivou a abordagem; com ele tinha duas porções de maconha e 180 reais em espécie; questionado, Gabriel disse que estava indo para a casa do ALEX SANDRO, com quem tinha mais de 20 porções de maconha e estava indo fazer o recolhe do dinheiro; a entrada na casa de ALEX SANDRO foi franqueada pelo réu e sua mãe; no quarto de ALEX SANDRO encontraram outras 28 porções de maconha; Gabriel disse que a quantidade maior de maconha estava na Avenida Amazonas; Gabriel abriu a porta e mostrou seu quarto; embaixo do colchão encontraram mais porções de maconha;

dentre de um copo descartável havia mais maconha solta; encontraram 11 reais em moeda e uma balança de precisão; ALEX SANDRO confirmou que era amigo de Gabriel; na casa de ALEX SANDRO não encontraram dinheiro; não acompanhou o depoimento de ALEX SANDRO na Delegacia e ele disse que era usuário no momento da abordagem; não conhecia ALEX SANDRO e nem sabia onde ele morava; também não conhecia Gabriel; o adolescente disse que conhecia a filha da policial Isabella; na abordagem na casa do ALEX SANDRO havia três policiais, o depoente, Isabella e outro policial; Gabriel disse que já havia sido conduzido à Delegacia pelo tráfico de drogas; na casa do adolescente foi ele próprio que abriu a porta, pois estava com a chave e disse que morava com avó, a qual estava trabalhando como cozinheira em um restaurante; na casa do ALEX SANDRO as porções estavam separadas já, não havia material para embalar; na casa de Gabriel havia porções pequenas, grandes e material para embalar.

A testemunha, Isabella Christine Fequette Baptista da Silveira, policial militar, ouvida em solo policial, disse que: é policial militar; na data em questão, estava juntamente com o segundo sargento PM Pucci, em patrulhamento de rotina no Bairro Jardim Europa na Avenida das Cerejeiras; visualizou o menor Gabriel Henrique Ferreira que ao avistar a viatura tentou correr desviou o seu rumo; o menor foi detido; na abordagem foi possível localizar consigo 02 porções de maconha e a quantia de R\$ 181,00 em dinheiro espécie; ao questioná-lo sobre a origem dos entorpecentes e do dinheiro, respondeu dizendo que estava indo na casa de seu colega ALEX fazer o "recolhe" do dinheiro, pois deixou com ele mais de 20 porções de maconha para ele vender; Gabriel mostrou onde ALEX morava, com isso a genitora de ALEX franqueou a entrada da equipe para entrar na casa; dentro de seu quarto, mais especificamente no guarda roupa fora possível localizar 28 porções de maconha; Gabriel o informou que reside na casa de sua avó na Avenida Amazonas no numeral 474, e que por lá guardava mais entorpecentes; Gabriel autorizou a entrada da equipe em sua casa; em seu quarto em baixo da cama mostrou onde guardava as drogas, totalizando mais 47 porções pequenas de maconha, 40 porções grande de maconha, 1 balança de precisão sem marca, embalagens para preparar as drogas e mais R\$ 11,80 em moedas; foi dado voz de prisão a ALEX e o menor conduzido até o plantão policial para registro de ocorrência (fls. 04).

Em juízo relatou que: durante um patrulhamento pelo bairro avistaram Gabriel que, ao avistar a viatura, acelerou o passo e foi abordado; com Gabriel havia duas porções de maconha e 181 reais em espécie; Gabriel declarou que estava indo a casa do amigo que tinha mais 20 porções que foram deixadas para venda; Gabriel levou os policiais até a casa de ALEX SANDRO; a mãe de ALEX SANDRO franqueou a entrada e lá encontraram outras porções de maconha; Gabriel disse que havia mais porções na sua residência; foram até a residência de Gabriel e encontraram mais porções de maconha; conduziram os dois para a Delegacia; na casa de Gabriel havia uma balança de precisão, porções grandes e pequenas e um pouco de droga dentro de um copo; existia porções com as mesmas embalagens plásticas na casa de ambos; entrou na residência de ALEX SANDRO; foi o sargento que encontrou as drogas; a depoente não falou com ALEX SANDRO; Gabriel disse que ia à casa de ALEX SANDRO fazer a "recolha"; não encontrou dinheiro na casa de ALEX SANDRO; não acompanhou os depoimentos na Delegacia; Gabriel citou o nome da filha da depoente em tom de ameaça; a filha da depoente não conhece Gabriel; a depoente tem nada contra o adolescente, nunca o tinha visto; Gabriel disse que estava vendendo entorpecentes; o adolescente abriu a porta da casa com as chaves que ele tinha; não havia outras pessoas na residência; a balança de precisão estava embaixo da cama, junto com as drogas.

A testemunha Gabriel Henrique Ferreira, ouvido em solo policial, disse que: estava transitando na rua do local dos fatos; foi surpreendido pela equipe da polícia militar que mandou o parar; questionaram se ele é filho de Fabiana; mandaram mostrar o que tinha nos bolsos; seu amigo ALEX estava ligando, visto que eles tinham combinado de consumir entorpecentes juntos; os policiais militares então pegaram o celular de sua mão e logo após disseram que se ele não assumisse os entorpecentes, ocasião na qual fora mostrado ao menor uma quantidade de pó iriam acusar a sua avó, como também o próprio declarante; mostrou onde ficava a casa de

ALEX; foram até o local; ficou dentro da viatura enquanto os policiais militares arrebentaram o portão da casa de ALEX; lá foi apreendido certa quantidade de drogas; não sabe qual é a origem dos entorpecentes dele; os policiais militares questionaram onde o declarante mora e foram até sua residência; chegando ao local, os policiais militares pegaram as chaves que estavam com o declarante; em seu quarto fora apreendido a quantidade maconha de aproximadamente 1 quilo, mas estavam todos separados; foi comprado dessa forma; os entorpecentes são para uso próprio, como também para usar com amigos, de forma compartilhada; o dinheiro que fora apreendido é proveniente de sua pensão; a balança é de propriedade de sua avó, visto que ela é cozinheira; após a apreensão das drogas os policiais militares pararam a viatura próximo a casa de sua avó e ficaram lá por algum tempo e ficaram conversando entre eles, não sabe especificar o teor da conversa; foram a delegacia; quando estava realizando o exame cautelar de corpo delito perguntou a policial que se por acaso conhecia Abidom que ele conheceria a sua filha, com isso a policial falou para não falar de sua filha; ao chegar à delegacia a mesma policial teria dito a ele que a sorte que havia uma cela para separar os dois, mas que depois quando ele estiver na rua eles iriam conversar; consome aproximadamente 25 gramas de maconha por dia sozinho, inclusive estava realizando tratamento no CAPS desta urbe com o fito de conseguir parar de fumar. (fls. 05).

Em juízo relatou que: estava indo na casa de ALEX SANDRO para consumirem drogas juntos; não encontraram nada com o depoente; tinha apenas 200 reais em espécie; pegaram o celular e jogaram no chão e fizeram o depoente desbloquear; viram a conversa com ALEX SANDRO; não indicou a casa de ALEX SANDRO aos policiais, que quebram a porta para entrar; eles foram chamando em várias casas; pegaram a chave do depoente e entraram sem autorização; o que tinha no quarto era do depoente mesmo; o que estava na casa de ALEX SANDRO também era do depoente; estava vendendo as drogas para pagar parcelado o que comprou; está devendo ainda; nem a avó e nem a mãe tinham ciência que o depoente tinha a droga; o ALEX SANDRO não vendia drogas para o depoente; a droga estava lá porque não estava sabendo onde guardar; jogou as drogas no quintal de ALEX SANDRO no dia anterior porque uma viatura passou; no dia seguinte avisou a ALEX SANDRO que as drogas estavam lá; não sabia que iam chegar nesse ponto; iam consumir juntos.

A testemunha de Defesa Valdinei Gomes dos Santos nada soube esclarecer sobre os fatos.

A informante da Defesa, Enesita Aparecida dos Santos, mãe do réu, disse que: encontraram uma 'porçãozinha' de droga com o filho; não viu a droga, acredita que foi 'uma só' porção; saiu e, mais tarde, ouviu uns barulhos de carro com viaturas; a policial feminina lhe orientou a não se aproximar, identificou-se e quis ingressar; outra viatura chegou, então entrou com o policial; afirmaram que encontraram 'porçãozinha' de droga, tendo levado para a Delegacia; não viu outro, viu apenas uma 'cabecinha' na viatura, não conhece Gabriel - nunca esteve em sua casa; sabia que o filho usava maconha, não permitia; o filho aludia a Gabriel, mas não o conhecia.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório, tem-se que o réu confessou a posse das drogas encontradas em sua residência, porém negou qualquer vínculo em relação aos entorpecentes apreendidos na casa do adolescente Gabriel. Negou que a droga apreendida fosse destinada ao comércio, pois se afirmou usuário.

A versão de ALEX SANDRO, entretanto, não encontrou respaldo nas demais provas dos autos. Embora Gabriel tenha tentado alterar sua versão em relação às declarações prestadas na fase policial, buscando em juízo isentar o réu de responsabilidade e assumindo a propriedade dos entorpecentes, observa-se que não fosse a indicação do adolescente de que estava indo fazer o recolhimento junto ao réu, os policiais não teriam motivos para se dirigir até sua residência.

Nenhum dos policiais conhecia ALEX SANDRO. Somente foram até o local pois Gabriel assim indicou, dando conta de que havia deixado entorpecentes para serem revendidos.

O relatório preliminar relativo aos dados extraídos dos celulares do réu e do adolescente (fls. 183-200) demonstrou a existência de vídeos com imagens de maconha enviados por Gabriel a ALEX SANDRO, sendo que o réu confirma que iria até o adolescente para buscar as porções para vender e levantar um dinheiro. Há, ainda, conversas do réu com um interlocutor identificado como Luiz Gustavo nas quais ALEX SANDRO negocia drogas.

Ademais, o relatório de fls. 249-307 é prova bastante contundente do envolvimento de Gabriel com a traficância. E a partir de fls. 304 verifica-se que ALEX SANDRO, ao contrário do que afirmou em juízo, não era simplesmente usuário. Ele manteve contato com uma pessoa conhecida como "Gustavo Patinho" solicitando entorpecentes para vender, insistindo para a liberação da droga ainda no mesmo dia do contato. Portanto, com a localização dos entorpecentes na residência de ALEX SANDRO, e as informações extraídas tanto de seu celular como do aparelho de Gabriel, há provas suficientes de autoria e materialidade do delito a justificarem a necessidade de responsabilização penal.

Uma ressalva precisa ser feita, entretanto.

Não há como responsabilizar ALEX SANDRO por todo o entorpecente apreendido com o adolescente Gabriel. As provas indicam que Gabriel era o fornecedor do réu, e não o contrário, como consta na denúncia.

Por isso, a responsabilidade criminal de ALEX SANDRO, no caso concreto, restringe-se ao tráfico de entorpecentes das 28 porções de maconha encontradas em sua residência. Mesmo a eventual comprovação da associação para o tráfico – fato que será analisado abaixo – não implica na imediata extensão da responsabilidade para todos os associados em relação às porções encontradas com cada um de seus membros, devendo ser apurada a conduta individualizada de cada membro para os fatos delitivos específicos praticados.

2.2 Sobre o delito de associação para o tráfico de drogas (FATO 02)

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 10-13), auto de exibição/apreensão (fls. 14-15 e 18-19), auto de constatação preliminar (fls. 16-17) laudos periciais (fls. 103-108, 109-112, 113-116, 119-122 e 123-128), análises investigativas de telefones celulares (fls. 183-200) e pela

prova oral colhida em juízo.

Nas linhas anteriores consta a referência à prova oral produzida nos autos. Da análise dos depoimentos e das demais provas dos autos, extrai-se haver e entre ALEX SANDRO e Gabriel para a traficância.

A evidência do vínculo repousa inicialmente na afirmação de Gabriel para as testemunhas Adriano e Isabella, dando conta de que ia até a casa de ALEX SANDRO para recolher o dinheiro do entorpecente deixado com o réu para o comércio e é reforçada pelas evidências extraídas dos aparelhos celulares de ambos.

Como assinalado, há conversa em que Gabriel envia imagens de diversas porções de maconha para ALEX SANDRO, o qual menciona sua intenção de logo buscar os entorpecentes. Vale ressaltar passagem na qual se verifica a existência de vínculo de confiança entre o adolescente e o réu. Com efeito, Gabriel afirma "moiado só solto de (sic) for na sua mão", e ALEX SANDRO logo assente com a gíria "pdp" (pode pá) e acrescenta "já colo aí buscar".

Com essa evidência, está suficientemente demonstrado a existência da associação entre Gabriel, o fornecedor (já que, como deu conta o relatório de fls. 249-307, ele mantém contato com diversas pessoas envolvidas no tráfico de drogas), e ALEX SANDRO, o vendedor.

Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria.

2.3 Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade

O réu, de forma consciente e espontânea, com a colaboração e envolvimento do adolescente Gabriel Henrique Ferreira, de 15 anos, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, tinham em depósito e mantinham a guarda, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 28 porções de maconha com massa bruta total de 42 gramas; e associou-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Essas condutas se amoldam formalmente à previsão abstrata do art 33, "caput", e art. 35, ambos c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Com isso, está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu ALEX SANDRO DOS SANTOS SILVA nas penas dos art. 33, "caput", e art. 35, ambos c.c. o ar. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

2.4 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.4.1 Dosimetria da pena

a) Para o crime de tráfico de entorpecentes (FATO 01)

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como circunstâncias; as consequências são inerentes ao tipo penal; por fim, o comportamento da vítima em nada facilitou para o cometimento da infração.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida apenas maconha. Não há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Em relação à quantidade, foram apreendidos, 28 porções de maconha com massa bruta total de 42 gramas. O montante não se mostra suficiente para ensejar maior reprovação.

Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, primeira parte, do Código Penal). Não há agravantes. Contudo, a pena foi fixada no mínimo legal e não pode ser reduzida aquém desse patamar nesta fase. Permanece a pena como lançada.

Por fim, na terceira fase, inviável a aplicação da redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas porque o réu também foi condenado pela associação para o tráfico de drogas. Por outro lado, está presente a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma Lei, pois vê-se que o crime envolveu o adolescente Gabriel, que forneceu a droga encontrada com o réu. Assim, aumento a pena em 1/6 e torno definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Para o crime de associação para o tráfico (FATO 02)

Na primeira fase da dosimetria aplicam-se as mesmas considerações lançadas no item "a", supra. Não convém repeti-las.

Por isso, fixo a pena base em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, primeira parte, do Código Penal). Não há agravantes. Contudo, a pena foi fixada no mínimo legal e não pode ser reduzida aquém desse patamar nesta fase. Permanece a pena como lançada.

Por fim, na terceira fase, não se aplica a redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas porque incompatível com a própria natureza do delito de associação para o tráfico. Por outro lado, verifica-se a presença da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

c) Concurso material

Conforme demonstrado, a agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos (associação para o tráfico e tráfico), assim, aplica-se a regra do concurso material (art. 69, do CP), na qual se cumulam as penas privativas de liberdade.

Portanto, a pena final alcança em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1399 dias-multa.

2.4.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim

sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão), o fato do réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2.4.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos e, portanto, não satisfaz o requisito objetivo para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), nem para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

2.4.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.4.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Recepção. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de

Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo.

Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ALEX SANDRO DOS SANTOS SILVA pela prática dos delitos previstos no art. 33, "caput" (FATO 01) e art. 35, ambos c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 9 anos, 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1399 dias-multa.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, já a evidenciou-se que o réu estava associado a outros indivíduos para a prática criminosas e a necessidade de pôr fim a essa associação é razão suficiente para a custódia cautelar.

Recomende-se a manutenção da custódia cautelar. Expeça-se a guia de recolhimento provisório.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 14-15 e 18-19 por ser produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSCGJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
- b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
- c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
- d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);

e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;

f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA